

1500686-82.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... fls. 192/3), a indicar que fazia do tráfico o seu meio de vida, conforme suspeitado pelos guardas municipais hoje ouvidos. Não bastasse, a corroborar tal conclusão, constato que o crescendo infracional na infância é deveras alarmante, afinal, foram quatro ocorrências versadas sobre atos infracionais equiparados ao crime de tráfico, três delas no ano de 2019 e uma no ano de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -

tatui2cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500686-82.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2130115/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 24943929 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIOVANI CECILIATO DE SOUZA SIMÃO e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" e Art. 35 "caput" ambos do SISNAD ambos c/c Art. 61 "caput", II, "j" c/c Art. 69 "caput" ambos do CP

Data da Audiência:

16/09/2022

Réu Preso

Aos 16 de setembro de 2022, às 13 horas, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, o Dr. Rafael Corrêa de Moraes Aguiar, Promotor de Justiça, o Réu GIOVANI CECILIATO DE SOUZA SIMÃO, acompanhado do Defensor, Dr. Alexandre Augusto Barreto da Silva, e o Réu THIAGO OLIVEIRA CARDOSO, acompanhado do Defensor, Dr. Roberto Alexandre dos Santos, bem como as testemunhas arroladas Márcio José Coelho (GCM) e Sandro de Oliveira (GCM). Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação

caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, o réu Giovani foi entrevistado de forma reservada por seu advogado; a defesa de Thiago informou já haver realizado a entrevista reservada com o acusado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo os Réus interrogados ao final. Quanto à manutenção das algemas, em observância ao que dispõe a súmula vinculante nº 11, ficou a critério do estabelecimento prisional, anotado que que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: “Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de GIOVANI CECILIATO DE SOUZA SIMÃO e THIAGO OLIVEIRA CARDOSO por suposta incursão na figura típica descrita no Art. 33 "caput" e Art. 35 "caput" ambos do SISNAD ambos c/c Art. 61 "caput", II, "j" c/c Art. 69 "caput" ambos do CP. Narra a denúncia (fls. 1/3) que, no mês de maio de 2022, nesta cidade e Comarca de Tatuí, GIOVANI CECILIATO DE SOUZA SIMÃO e THIAGO OLIVEIRA CARDOSO, ambos qualificados nestes autos, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico. Ainda, no dia 15 de maio de 2022, por volta das 22h50, na rua João Abrami, nº 406, Jardim Santa Rita de Cássia, nesta cidade e Comarca de Tatuí, GIOVANI CECILIATO DE SOUZA SIMÃO e THIAGO OLIVEIRA CARDOSO, previamente ajustados, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, traziam consigo, tinham em depósito e guardavam, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 05 porções de cocaína com peso bruto aproximado de 6,7 gramas; 02 porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como “maconha”, com peso bruto aproximado de 3,6 gramas e 23 porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como “maconha”, com peso bruto aproximado de 45,9 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Apurou-se que os denunciados praticavam o tráfico, dividindo as tarefas na empreitada criminoso. Para tanto, THIAGO trazia porções de drogas em mãos, de forma a facilitar as entregas aos interessados, enquanto GIOVANI guardava o dinheiro auferido com a comercialização. E, visando dificultar a apreensão, os denunciados guardavam o restante dos entorpecentes no terreno baldio situado nas imediações do “ponto de vendas”. Guardas Civis Municipais efetuavam patrulhamento de rotina – em local conhecido pela intensa mercancia ilícita – quando avistaram os denunciados saindo do terreno baldio. GIOVANI e THIAGO, ao notarem aproximação da viatura, demonstraram evidente nervosismo, mudando de comportamento. Houve a abordagem e, na revista pessoal, com THIAGO foram encontradas 05 porções de cocaína e 01 porção de “maconha”. Com GIOVANI foram localizados R\$ 85,00 e o aparelho de telefonia celular. No referido terreno foram encontradas, nas proximidades de onde os denunciados foram avistados, mais 24 porções de “maconha”. Auto de prisão em flagrante às fls. 6 e 30. Soltos em audiência de custódia às fls. 49/50. Decretada a prisão preventiva de Giovani às fls. 123. Auto de exibição e apreensão às fls. 23/4. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 17/8. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 85/90. Informação sobre o local dos fatos às fls. 91/2. Notificação de Thiago às fls. 98. Notificação de Giovani às fls. 139. Defesa preliminar de Thiago apresentada às fls. 124/5. Não foram arroladas testemunhas pela Defesa. Defesa Preliminar de Giovani às fls. 149/50, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum à Acusação. Constan nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome dos Réus. A denúncia foi recebida em 08/09/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 227/8). Citação de Thiago às fls. 237. Citação de Giovani às fls. 243. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. Os Réus foram interrogados ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E

DECIDO. Inicialmente, de ofício, observo que não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, uma vez que não emerge, dos interrogatórios, a despeito das alegações sobre utilização de maconha (inclusive, quanto a Giovani, no interrogatório de solo investigativo, conforme já registrei ao sentenciar o feito certificado às fls. 192/3, fora observado por esse sentenciado não ser viciado em drogas), qualquer indício de que sejam incapazes de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Outrossim, não houve a juntada de qualquer documento médico que indique o contrário. Enfim, tirocínios preservados, conforme se observou durante o ato. Ainda, preliminarmente, anoto que o oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, conforme registrei às fls. 80, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão, em hipótese na qual, acresça-se, os interrogados não são confessos. Por fim, nesta sede, no que atine à alegação de irregularidade na atuação da guarda, respeitados posicionamentos em sentido diverso e a natural combatividade da defesa, fato é que qualquer do povo possui a prerrogativa de prender, em flagrante delito, aquele que se encontre cometendo um crime permanente, não se estranhando que agentes públicos assim o façam logo que se deparam com um cenário dessa natureza, ainda que a instituição não seja naturalmente vocacionada a tal mister, pois, saúde e segurança públicas são valores a serem prestigiados, sempre, não se imaginando que no contexto aqui versado, no qual se elucidou a custódia de drogas tanto junto de um dos acusados quanto em terreno abandonado, os agentes tivessem de suspender a diligência para postular pela intervenção de outras forças ou ordem judicial. Ultrapassadas essas pontuações, no mérito, a ação penal procede, em parte, desde logo explicado o parcial revés da postulação ministerial na absolvição quanto à imputação de associação, conforme pugnado, inclusive, pelo representante ministerial que apresentou as alegações finais orais nesta solenidade. A propósito, recentemente alterei o entendimento a respeito da configuração da associação, passando a exigir a estabilidade, definição que demanda justificativa, em atenção à obrigação decorrente do poder/dever de julgar, de prestação de contas à sociedade, a fim de que se exerça na sua mais ampla extensão o controle democrático do exercício desse poder, de dizer o direito. E a alteração veio, como sempre, na filosofia da garantia da isonomia entre os jurisdicionados, na realidade da Comarca, mas também em atenção à orientação predominante dos Tribunais Superiores, notadamente diante da natureza do interesse aqui versado, a liberdade. Isso porque, consultando a jurisprudência do Egrégio Tribunal Bandeirante, especialmente v. acórdãos proferidos durante o ano de 2019, versados sobre sentenças da lavra deste magistrado, localizou-se ao menos 18 ocorrências, 15 das quais importaram em reformas parciais das condenações para absolvição de Réus, então condenados pelo delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas. Sem analisar caso a caso, para evitar despropositado elastério, consigo que foram mantidas as condenações nos autos dos Apelos: (i) 1500769-40.2018.8.26.0571 (Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Jaime Ferreira Menino, D.J. 24/09/2019); (ii) 1500936-57.2018.8.26.0571 (Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Luiz Antônio Cardoso, D.J. 13/08/2019) e (iii) 000616-81.2018.8.26.0571 (Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Euvaldo Chaib, D.J. 26/02/2019). De outro turno, houve reforma nos autos dos apelos:

(1) 1500065-90.2019.8.26.0571 (Colenda 1ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Mário Devienne Ferraz, D.J. 07/10/2019); (2) 1500612-80.2018.8.26.0599 (Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Roberto Porto, D.J. 24/09/2019); (3) 0002671-11.2016.8.26.0624 (Colenda 5ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Damião Cogan, D.J. 05/09/2019); (4) 1500868-10.2018.8.26.0571 (Colenda 2ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Francisco Orlando, D.J. 19/08/2019); (5) 0000653-45.2017.8.26.0571 (Colenda 14ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Marco de Lorenzi, D.J. 01/08/2019); (6) 0000987-79.2017.8.26.0571 (Colenda 10ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Nelson Fonseca Júnior, D.J. 25/07/2019); (7) 1500697-53.2018.8.26.0571 (Colenda 10ª Câmara de Direito Criminal, Relatora Desembargadora Rachid Vaz de Almeida, D.J. 04/07/2019); (8) 0000032-

19.2015.8.26.0571 (Colenda 15ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Cláudio Marques, D.J. 16/05/2019); (9) 0000422-81.2018.8.26.0571 (Colenda 13ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro, D.J. 24/04/2019); (10) 0011026-73.2017.8.26.0624 (Colenda 1ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Figueiredo Gonçalves, D.J. 08/04/2019); (11) 0000181-78.2016.8.26.0571 (Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Euvaldo Chaib, D.J. 26/03/2019); (12) 0000430-58.2018.8.26.0571 (Colenda 6ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Lauro Mens de Mello, D.J. 21/03/2019); (13) 0000574-32.2018.8.26.0571 (Colenda 9ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Costabile e Solimene, D.J. 14/02/2019); (14) 1500181-33.2018.8.26.0571 (Colenda 7ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Eduardo Abdalla, D.J. 13/02/2019) e (15) 1500160-57.2018.8.26.0571 (Colenda 11ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Salles Abreu, D.J. 12/12/2018).

Como visto, nessa breve compilação, variadas Câmaras do Egrégio Tribunal de Justiça têm exigido, para manutenção da condenação pelo crime de associação, a prova da estabilidade. É certo que, em alguns casos, essa conclusão é extraída da quantia de envolvidos, do fato de eventualmente serem parentes ou residirem sob o mesmo endereço, bem como da quantidade de entorpecente apreendido, numa aproximação da figura do art. 35 com o profissionalismo para a traficância, porém, via de regra, a prova da estabilidade é exigida, ainda que a interpretação possa se fazer de forma casuística, de modo que, em linhas gerais, agora, o julgador passa a se curvar à orientação estabelecida, sem caráter vinculante, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 139.942/SP, julgado em 19/11/2012, e de cuja ementa do V. Acórdão se extrai, no que interessa: "Exige-se o dolo de se associar com permanência e estabilidade para a caracterização do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06". Na mesma ementa, consignou-se a atipicidade da conduta se esse ânimo associativo não for permanente, mas apenas esporádico, eventual, justamente o que se verifica na hipótese entre Giovani e Tiago, ao menos a partir das provas trazidas pela acusação. Lembre-se que os guardas responsáveis pela diligência, embora conhecessem ambos pelo envolvimento com o mundo do tráfico, não trouxeram qualquer notícia sobre a traficância conjugada entre eles antes daquele dia. Diante disso, não se afasta a possibilidade de que, até o dia dos fatos, quando evidentemente incidiram na mesma conduta típica, traficassem por conta própria. Assim, embora este juízo ainda faça a ressalva do seu posicionamento, não mais se sustentando dispensar a estabilidade para efeitos da caracterização do crime de associação para o tráfico, pena de comprometer a isonomia merecida pelos réus diante de entendimento que se afirma dominante, a absolvição no que atine à imputação de infração ao disposto no art. 35, da Lei de Drogas é medida que se impõe em relação a ambos. Aproveito o momento para constar, a respeito da manifestação em sede de alegações orais e a despeito de inexistir postulação nesse sentido na prefacial, que o estabelecimento tipo igreja mencionado nas informações de fls. 91/2 não preenche a tipicidade legal do art. 40, III, da Lei de Drogas e, não fosse o bastante, sequer se tem notícia de que na hora da diligência, 22:50hs, estivesse aberto e frequentado, de modo que não se pode dizer tenha sido o interesse penalmente tutelado colocado em maior risco nessa traficância exercida em via pública e não a partir de residência, embora a de um dos réus, Thiago, fosse próxima dali. Pois bem, ressalva feita, autoria e materialidade delitivas do crime de tráfico imputado na denúncia restaram suficientemente comprovadas nos autos. Com efeito, ouvidos nesta teleaudiência, realizada na esteira da deliberação de fls. 227/8, e em atenção ao princípio da razoável duração do processo que conta com Réu preso, os guardas municipais Márcio e Sandro (faz-se uma suma síntese de seus depoimentos, que se complementam sem contradições), antes declinando que conheciam os Réu de outras abordagens, com a nota de que Thiago seria gerente e Giovani traficante de outra região, narraram que patrulhando pela região, conhecido ponto desse comércio, notaram ambos deixando juntos um terreno, razão da abordagem, com Giovani encontrados celular e R\$85,00 e com Thiago, 5 porções de cocaína e 1 porção de maconha, sendo que as diligências imediatamente se estenderam para o terreno deixado por eles, ali apreendidas outras 24 porções de maconha. Parêntesis seja

aberto para consignar que a potencialidade lesiva das substâncias veio atestada no laudo de fls. 85/90, como sendo: 5 porções de cocaína, com 5,11 gramas líquidos; 23 porções de maconha, com 36,51 gramas líquidos e 2 porções de maconha, com 3,08 gramas líquidos. Interrogados, tal qual em solo policial, fls. 13 e 15, os acusados negaram a traficância e a posse de qualquer porção de droga, salientando, inclusive, que o celular pertencia a Thiago e não a Giovani, conforme propalado pelos guardas que os perseguem, especial destaque para o GCM Márcio. Giovani acresceu que chegava por ali e não estava com Thiago, no que foi desautorizado por esse último, morador da região, que disse conversava com o corréu há uns dez minutos. Desacreditadas as versões dos acusados ao desvirtuar a disposição das drogas e negar a responsabilidade por todas elas, a indicar que sejam mesmo os corresponsáveis pela integralidade, mesmo porque, incrementada essa conclusão pela contradição sobre estarem juntos, o que vem admitido por aquele encontrado com drogas, a sugerir que o outro, Giovani, seu comparsa, tem mesmo todo o interesse em desautorizar as versões dos agentes públicos, justamente diante da sua participação na empreitada criminosas. Ademais, o próprio contexto legitimou as buscas nas proximidades e a localização do estoque considerável só foi possível porque os agentes foram vistos saindo juntos do terreno, e aí já a diversidade, número, pesagem e locais de custódia são no seu conjunto incompatíveis com a condição de posse para mero uso. Enfim, a despeito de casual a abordagem, estabelecido um cenário de traficância, no qual surpreendidos Giovani e Thiago, manuseando em conjunto entorpecentes variados e custodiando numerário decorrente de tais atividades (R\$85,00), pese não visualizados em ato efetivo de venda, o que se mostra prescindível na hipótese, aliás, *modus operandi* bem conhecido, tendente a minimizar os riscos de um flagrante, a guarda de parte menor das porções junto ao corpo e do grosso do estoque em área próxima, bem como do numerário com aquele que não se encontra com o entorpecente, restando assim preenchidos alguns dos núcleos verbais do tipo múltiplo alternativo do art. 33 da Lei 11.343/06, notadamente sob as formas trazer consigo e guardar. Quanto ao fato de serem eventualmente usuários, mas de apenas uma das drogas apreendidas, a menos lesiva (maconha), e do que, repita-se, não há menor comprovação nos autos, não exclui, senão facilita as suas atividades ilícitas, pelo dilargado acesso a outros traficantes e usuários, seus compradores. Por fim, numerário e celular obviamente relacionados às atividades criminosas daqueles que não comprovaram labor lícito, e pertencesse o aparelho a qualquer dos concursados, deverão ter as suas perdas decretadas. Comprovadas, portanto, autoria e materialidade apenas e tão somente do crime de tráfico imputado aos acusados na denúncia, os quais devem ser absolvidos da imputação de associação, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico e atento à disciplina própria da lei de tóxicos. Quanto ao Réu GIOVANI CECILIATO DE SOUZA SIMÃO: Na primeira fase, há circunstância judicial desfavorável, afinal, a despeito de o estoque variado não ser expressivo, a traficância era exercida em concurso, o que incrementa o poder de vulneração ao interesse penalmente tutelado. Não bastasse, além do passado infracional que será abordado linhas adiante, fato é que Giovani, liberado na custódia deste flagrante, fls. 49/50, apenas dois meses após, frustrando a confiança do juízo, tornou a delinquir, por isso condenado por este magistrado por sentença pendente de trânsito em julgado nos autos do processo certificado às fls. 192/3, e isso notoriamente representa inadequação da personalidade a ser reprimida pela pedagogia da pena. Por tais razões, elevo em 1/6 a pena-base, estabelecendo-a em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, cada qual no mínimo, à míngua de elementos a respeito da capacidade financeira do Réu. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda. Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, "j", CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito

Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), a qual fica compatibilizada com a atenuante da menoridade relativa, fls. 158, daí inalterada a pena. Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que o agente denotando ousadia, profissionalismo e potencial capacidade para atingir o bem juridicamente tutelado, já se disse na primeira fase, traficava com maconha e cocaína, ilícito no qual tornou a incidir enquanto gozando da liberdade provisória concedida neste flagrante (certidão às fls. 192/3), a indicar que fazia do tráfico o seu meio de vida, conforme suspeitado pelos guardas municipais hoje ouvidos. Não bastasse, a corroborar tal conclusão, constato que o crescendo infracional na infância é deveras alarmante, afinal, foram quatro ocorrências versadas sobre atos infracionais equiparados ao crime de tráfico, três delas no ano de 2019 e uma no ano de 2020, a última culminada em internação, já que nas anteriores recebera apenas e tão somente a medida de liberdade assistida. Aliás, compulsando as certidões encartadas às fls. 169/71; 174/7; 178/82 e 183/8, constato que as apreensões foram de crack, droga que o interrogado não utiliza, duas delas em quantidade igual ou superior a seis dezenas. Não é, portanto, neófito na criminalidade, notadamente na traficância, seja pela variedade e qualidade do entorpecente manuseado, pese não exorbitante, seja pelos inúmeros envolvimento anteriores na recente infância e pela prática de crime similar após ser liberado na presente custódia, e isso desautoriza a aplicação da benesse, sujeita à apreciação do julgador nas circunstâncias do caso concreto, haja vista a utilização do verbo "poderá". E compete a esse mesmo julgador analisar o caso sob as luzes do art. 42, da mesma Lei de Drogas, ou seja, enfocando de modo preponderante as circunstâncias mencionadas. Deve ser respeitada a política do desencarceramento, uma vez legislada e integrada na interpretação dos Tribunais Superiores, todavia, há que se proteger, igualmente, a sociedade, uma vez que segurança e saúde públicas também são princípios constitucionais, de modo que, a particularidade do caso não permite seja o acusado agraciado com tais medidas, recentemente alterados por este magistrado os critérios de aplicação do próprio redutor de molde a compatibilizar a intenção dos Tribunais Superiores e do legislador infraconstitucional (refiro-me ao art. 112, § 5º, da Lei 7.210/84, na redação dada pela Lei 13.964/19), de repressão menos severa ao chamado traficante de "primeira viagem", com a necessidade de apenar adequadamente aquele que coloca em sério risco o meio social. Respeitosa jurisprudência admite a consideração do passado infracional a título de afastamento do redutor. E se há dúvidas a respeito da pertinência de tal solução, confira-se lição haurida do julgamento do Apelo 0000885-57.2017.8.26.0571, Relator Desembargador Hermann Herschander, Colenda 14ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal Bandeirante, d.J. 26/04/18, nos termos do v. Voto condutor do qual se extrai, no ponto confirmando a solução dada por este juízo, inclusive com supedâneo em decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o que segue: "[...] Não é o apelante, à toda evidência, o traficante principiante, a quem se destina o apenamento mais brando. [...] Registra-se, ainda, que o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, por suas duas turmas criminais, firmou entendimento de que a prática de atos infracionais revela por parte de seu agente a dedicação à atividade criminosa [...]". Também, em caso de envolvimento pretérito, e o mesmo raciocínio vale para o posterior, enquanto no gozo de liberdade provisória, já decidi nesta Vara, com confirmação pelo Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação 0004345-24.2016.8.26.0624, Colenda 9ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Amaro Thomé, e o entendimento não deixa de encontrar arrimo em julgados do Tribunal encarregado de garantir a inteireza positiva do ordenamento infraconstitucional pátrio, conforme se verifica no AgRg no AREsp 1663087/MG, Colenda Sexta Turma, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, d.J. 16/06/20, de cuja ementa extraio: "[...] AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REGIME E SUBSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual - dentro do seu livre convencimento motivado - considerou que as circunstâncias em que praticado o crime e o fato de o acusado responder a outro

processo pela prática do delito de tráfico de drogas evidenciariam a sua dedicação a atividades delituosas, notadamente ao narcotráfico, e, portanto, impossibilitariam a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. Embora seja certo que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais em andamento, ou mesmo de condenações ainda sem a certificação do trânsito em julgado, não possa ser sopesada para exasperar a reprimenda-base - consoante o enunciado na Súmula n. 444 deste Superior Tribunal -, não há óbice a que tais elementos possam, à luz das peculiaridades do caso concreto, ser considerados para demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração delitiva (ensejando, por conseguinte, a necessidade de prisão preventiva para a garantia da ordem pública) ou mesmo para evidenciar, como no caso, a dedicação do acusado a atividades delituosas.[...]. Assim, à míngua de outras causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição, torno definitiva a reprimenda retro. O regime de cumprimento será o inicial fechado, sendo necessários investimentos ressocializadores acentuados em face de sujeito que se envolve reiteradamente em episódios de traficância, desde a infância recente, doravante vinculado a traficância com dois tipos de entorpecente e que reitera no cometimento enquanto no gozo de liberdade provisória, lembrando que se trata de crime equiparado ao hediondo, sendo aplicável o disposto no artigo 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90. Anoto que o tráfico é crime que vem comprometendo sensivelmente as estruturas familiares e sociais, sendo estopim para a prática de outros crimes tão graves quanto ele, tais como roubos e homicídios, por isso cabendo ao legislador a fixação do regime adequado à repressão da conduta e ressocialização do indivíduo, sendo vedado ao Judiciário interferir nessa opção democrática quando os demais elementos desautorizam tal desvirtuamento. Quanto ao regime inicial mais gravoso, a despeito da primariedade, chamo, ainda, à colação, incrementando as circunstâncias particulares deste caso concreto, lição exarada no julgamento da Apelação nº 0001010-25.2017.8.26.0571, por parte da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, extraída do V. Acórdão relatado pelo Desembargador Alexandre Almeida, datado de 29 de agosto de 2018, no bojo do qual mantida, nesse particular, sentença deste juízo, verbis: "[...] Em relação ao regime de cumprimento de pena, cumpre considerar que o tráfico de drogas causa indiscutível abalo à ordem pública, na medida em que o traficante consegue atingir um número elevado de pessoas, que acabam se envolvendo em outros delitos. Por isso, de rigor a segregação do agente por mais tempo no regime fechado, onde poderá demonstrar aptidão e preparo para voltar a conviver em sociedade. Tampouco é o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o traficante, longe de ser agraciado com os benefícios reservados a crimes menos graves, deve ser retirado da sociedade, cada vez mais temerosa e abalada com o avanço da criminalidade [...]. Incabível qualquer espécie de substituição, tendo em conta as circunstâncias judiciais absolutamente desfavoráveis, bem como a própria quantidade de reprimenda. Registre-se que não incide aqui, afastado que foi o redutor, a determinação do Colendo STJ nos autos do HC 596603/SP. A propósito, também não olvido, embora não vinculante nesse particular em que afastado o redutor, e a pena é inferior a oito anos de privação de liberdade, a linha de fundamentação exarada no v. Decisum mencionado, a sugerir a aplicação do disposto no art. 33, § 2º, "b", do CP, qual seja, o regime inicial semiaberto, ocorre que, dentre todos os argumentos já enfocados para o caso específico do sentenciado, sobressai a sua irrefreável propensão para o tráfico desde os tempos da recente infância, nos quais ostentou quatro ocorrências significativas, a última reprimida com internação, inservível para conter esse ímpeto, e também na maioridade, mesmo porque, pasme, liberado na presente custódia, tornou a incidir em ato de traficância, em virtude do qual se encontra recluso, de modo que os investimentos devem vir, mesmo, acentuados. Quanto ao Réu THIAGO DE OLIVEIRA CARDOSO: Na primeira fase, a circunstância judicial desfavorável que milita em relação a esse réu, lembrado que o estoque não se mostrou expressivo e que o passado infracional será abordado na fase derradeira, é o concurso de agentes, todavia, no contexto, reputo adequada a sua consideração apenas na fase derradeira, para os fins de afastamento do redutor. Pena-base no mínimo legal, 05 anos de reclusão

e 500 dias-multa, cada qual no mínimo, à míngua de elementos a respeito da capacidade financeira do Réu. Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, "j", CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), a qual fica compatibilizada com a atenuante da menoridade relativa, fls. 165, daí inalterada a pena. Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que o agente denotando ousadia, profissionalismo e potencial capacidade para atingir o bem juridicamente tutelado, já se disse na primeira fase, traficava com maconha e cocaína, embora não expressivo o estoque, e em concurso de agentes, a incrementar as possibilidades de sucesso da empreitada e atingimento do interesse penalmente tutelado, indicativos de que fazia do tráfico o seu meio de vida, conforme suscitado pelos guardas municipais hoje ouvidos, os quais o tem por "gerente" dessa espécie de comércio. Não bastasse, a corroborar tal conclusão, constato que o crescendo infracional na infância é deveras alarmante, afinal, apenas de ato infracional equiparado ao crime de tráfico foram seis ocorrências, distribuídas entre os anos de 2016, 2018 e 2020, e se outrora fora beneficiado com remissão ou liberdade assistida (certidões às fls. 194, 199 e 207/11), em nada menos de três oportunidades recebeu a medida de internação (certidões às fls. 202/6, 213/7 e 218/24), as quais se mostraram inócuas, conforme agora se vê. Não é, portanto, neófito na criminalidade, notadamente na traficância, seja pela variedade e qualidade do entorpecente manuseado, pese não exorbitante, seja pelos inúmeros envolvimento anteriores na recente infância, mormente pelas reiteradas internações, inservíveis para conter a sua propensão para a espécie de ilícito, e isso desautoriza a aplicação da benesse, sujeita à apreciação do julgador nas circunstâncias do caso concreto, haja vista a utilização do verbo "poderá". E compete a esse mesmo julgador analisar o caso sob as luzes do art. 42, da mesma Lei de Drogas, ou seja, enfocando de modo preponderante as circunstâncias mencionadas. Deve ser respeitada a política do desencarceramento, uma vez legislada e integrada na interpretação dos Tribunais Superiores, todavia, há que se proteger, igualmente, a sociedade, uma vez que segurança e saúde públicas também são princípios constitucionais, de modo que, a particularidade do caso não permite seja o acusado agraciado com tais medidas, recentemente alterados por este magistrado os critérios de aplicação do próprio redutor de molde a compatibilizar a intenção dos Tribunais Superiores e do legislador infraconstitucional (refiro-me ao art. 112, § 5º, da Lei 7.210/84, na redação dada pela Lei 13.964/19), de repressão menos severa ao chamado traficante de "primeira viagem", com a necessidade de apenar adequadamente aquele que coloca em sério risco o meio social. Respeitosa jurisprudência admite a consideração do passado infracional a título de afastamento do redutor. E se há dúvidas a respeito da pertinência de tal solução, confira-se lição haurida do julgamento do Apelo 0000885-57.2017.8.26.0571, Relator Desembargador Hermann Herschander, Colenda 14ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal Bandeirante, d.J. 26/04/18, nos termos do v. Voto condutor do qual se extrai, no ponto confirmando a solução dada por este juízo, inclusive com supedâneo em decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o que segue: "[...] Não é o apelante, à toda evidência, o traficante principiante, a quem se destina o apenamento mais brando. [...] Registra-se, ainda, que o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, por suas duas turmas criminais, firmou entendimento de que a prática de atos infracionais revela por parte de seu agente a dedicação à atividade criminosa [...]". Assim, à míngua de outras causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição, torno definitiva a reprimenda retro. O regime de cumprimento será o inicial fechado, sendo necessários investimentos ressocializadores acentuados em face de sujeito que se envolve reiteradamente em episódios de traficância, ostentando inúmeras ocorrências e três internações definitivas desde a infância

recente, em vários dos episódios apanhado em concurso de agentes (fls. 194/8; 202/6; 207/11) doravante vinculado a traficância com dois tipos de entorpecente, novamente em concurso, lembrando que se trata de crime equiparado ao hediondo, sendo aplicável o disposto no artigo 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90. Anoto que o tráfico é crime que vem comprometendo sensivelmente as estruturas familiares e sociais, sendo estopim para a prática de outros crimes tão graves quanto ele, tais como roubos e homicídios, por isso cabendo ao legislador a fixação do regime adequado à repressão da conduta e ressocialização do indivíduo, sendo vedado ao Judiciário interferir nessa opção democrática quando os demais elementos desautorizam tal desvirtuamento. Quanto ao regime inicial mais gravoso, a despeito da primariedade, chamo, ainda, à colação, incrementando as circunstâncias particulares deste caso concreto, lição exarada no julgamento da Apelação nº 0001010-25.2017.8.26.0571, por parte da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, extraída do V. Acórdão relatado pelo Desembargador Alexandre Almeida, datado de 29 de agosto de 2018, no bojo do qual mantida, nesse particular, sentença deste juízo, verbis: "[...] Em relação ao regime de cumprimento de pena, cumpre considerar que o tráfico de drogas causa indiscutível abalo à ordem pública, na medida em que o traficante consegue atingir um número elevado de pessoas, que acabam se envolvendo em outros delitos. Por isso, de rigor a segregação do agente por mais tempo no regime fechado, onde poderá demonstrar aptidão e preparo para voltar a conviver em sociedade. Tampouco é o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o traficante, longe de ser agraciado com os benefícios reservados a crimes menos graves, deve ser retirado da sociedade, cada vez mais temerosa e abalada com o avanço da criminalidade [...]". Incabível qualquer espécie de substituição, tendo em conta as circunstâncias judiciais absolutamente desfavoráveis, bem como a própria quantidade de reprimenda. Registre-se que não incide aqui, afastado que foi o redutor, a determinação do Colendo STJ nos autos do HC 596603/SP. A propósito, também não olvido, embora não vinculante nesse particular em que afastado o redutor, e a pena é inferior a oito anos de privação de liberdade, a linha de fundamentação exarada no v. Decisum mencionado, a sugerir a aplicação do disposto no art. 33, § 2º, "b", do CP, qual seja, o regime inicial semiaberto, ocorre que, dentre todos os argumentos já enfocados para o caso específico do sentenciado, sobressai a sua irrefreável propensão para o tráfico desde os tempos da recente infância, nos quais ostentou inúmeras ocorrências significativas, três delas reprimidas com internações, inservíveis para conter esse ímpeto, agora na maioria considerada por agentes públicos como "gerente" da traficância, de modo que os investimentos devem vir, mesmo, acentuados. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para, ABSOLVIDOS os réus da acusação de infração ao disposto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, isso com fundamento no art. 386, VII, do CPP, CONDENAR GIOVANI CECILIATO DE SOUZA SIMÃO, por incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, cada qual no mínimo legal; e CONDENAR THIAGO OLIVEIRA CARDOSO, por incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Descabida, nesse momento, a aplicação do disposto no art. 387, §2º do CPP, tendo em vista a ausência de lapso. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos, eis que relacionados ao tráfico. O réu Thiago poderá recorrer em liberdade, tendo em vista a decisão proferida em audiência de custódia às fls. 49/50 e a inalteração do estado de fato a permitir a revisão dessa situação processual, com a nota de que compareceu aos atos instrutórios. O réu Giovanni não poderá recorrer em liberdade, uma vez que as circunstâncias que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva às fls. 123 restam agora incrementadas pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, haja vista a substancial condenação imposta, a ser cumprida em regime inicial fechado, por indivíduo submerso no mundo da traficância desde a recente infância e que frustrou a confiança que lhe fora outrora estabelecida pelo

juízo da custódia nestes autos, primeiro furtando-se a manter-se no endereço informado e, depois, praticando novo crime de tráfico pelo qual acabou condenado por sentença pendente de trânsito (certidão às fls. 192/3), tudo a reclamar sejam acauteladas a ordem, segurança e saúde públicas. Recomende-se-o, portanto, no presídio em que se encontra recolhido. Expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória. Após o trânsito em

juízo, lance-se o nome dos Réus no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da gratuidade. Uma vez que os Réus manifestaram o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 143)". Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA